

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1512/2551

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
นายบุญเหลือ ขวัญเถื่อน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 81

การกระทำที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตาม ป.อ. มาตรา 81 ต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือวัตถุซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถจะกระทำให้บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เช่น หญิงไม่มีช่องคลอดอันเป็นการผิดปกติมาแต่กำเนิด ซึ่งอย่างไรก็ดี อวัยวะเพศชายก็ไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงดังกล่าวได้ อวัยวะเพศชายสามารถเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายได้แต่ช่องคลอดจะฉีกขาดและจะต้องมีการบังคับขู่เข็ญหรือใช้สารหลอหลอน ซึ่งไม่ใช่กรณีที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ การกระทำของจำเลยที่กระทำต่อผู้เสียหายจึงไม่ใช่กรณีที่ปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามความหมายในมาตรา 81

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เวลากลางวัน จำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กหญิง ม. ผู้เสียหายที่ 1 อายุ 5 ปีเศษ ไปเสียจากนาง ส. ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ดูแล เพื่อการอนาจารและจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมิใช่ภริยาของจำเลย 1 ครั้ง จำเลยกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล

เนื่องจากอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 เล็กจ๋มเลยจึงไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 80, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุเด็กหญิง ม. ผู้เสียหายที่ 1 อายุ 5 ปีเศษ ก่อนเกิดเหตุนาง ม. มารดาผู้เสียหายที่ 1 นำผู้เสียหายที่ 1 ไปฝากนาง ส. ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นป้าผู้เสียหายที่ 1 ให้เป็นผู้ดูแล บ้านจำเลยอยู่ใกล้กับบ้านผู้เสียหายที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา นายต๋องซึ่งเป็นบุตรชายจำเลยไปที่บ้านผู้เสียหายที่ 2 และพาผู้เสียหายที่ 1 และน้องสาวผู้เสียหายที่ 1 ไปเล่นที่บ้านจำเลย หลังจากนั้นผู้เสียหายที่ 2 และนาย ว. สามีผู้เสียหายที่ 2 จะไปเยี่ยมบุตรชายซึ่งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล จึงฝากให้จำเลยช่วยดูแลผู้เสียหายที่ 1 สำหรับข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์

ไม่อุทธรณ์ ขอดำท่งกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาหรือไม่....

พิเคราะห์แล้ว สำหรับปัญหาตามฎีกาของจำเลยประการแรกนั้น โจทก์มีผู้เสียหายทั้งสอง นาย ว. นาย ธ. ดาบทำรวจ บ. และร้อยตำรวจโท พ. เป็นพยานเบิกความประกอบกันได้ความตามที่กล่าวไว้ในทางนำสืบของโจทก์ข้างต้น เห็นว่า ผู้เสียหายที่ 1 เป็นเด็กหญิงอายุเพียง 5 ปีเศษ หากเรื่องราวตามคำเบิกความมิได้เกิดขึ้นจริง ก็ยากที่ผู้เสียหายที่ 1 จะปั้นแต่งเรื่องขึ้นปรักปรำจำเลยได้ถึงเพียงนั้น และผู้เสียหายที่ 1 ยังเป็นเด็กนักเรียน แต่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากจะนำมาเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้ ผู้เสียหายที่ 1 ย่อมไม่อาจเสแสร้งเอาความเท็จมาแถลงกล่าวหาจำเลยให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ตัวผู้เสียหายที่ 1 เอง ประกอบกับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 ก็เล่าเหตุการณ์ที่ถูกจำเลยล่วงละเมิดทางเพศให้ผู้เสียหายที่ 2 และนาย ว. ซึ่งเป็นป้าและลุงฟัง เมื่อผู้เสียหายที่ 2 ขอดูอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ก็พบว่ามียอวัยแดงและซ้ำ และผู้เสียหายที่ 1 บอกว่าเจ็บมาก ผู้เสียหายที่ 2 จึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งทั้งผู้เสียหายที่ 2 และนาย ว. ต่างก็เบิกความยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ความจากนาย ธ. แพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์ร่างกายของผู้เสียหายที่ 1 ว่า ได้ตรวจอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 พบว่าบริเวณเยื่อพรหมจารีมีรอยซ้ำและเลือดออกเล็กน้อย รอยซ้ำที่เยื่อพรหมจารีนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากของแข็งไม่ทราบชนิดกระแทกตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.4 อันเป็นการสนับสนุนถ้อยคำของผู้เสียหายที่ 1 ให้น้ำหนักมากยิ่งขึ้น และพยานโจทก์ยังเบิกความเชื่อมโยงสอดคล้องกันเป็นลำดับโดยปราศจากพิรุณสงสัย อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลย ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ยังมีพิรุณขัดกับความเป็นจริง กล่าวคือจากภาพและเสียงจาก

แผ่นวิธีดีที่ผู้เสียหายที่ 1 ให้การไว้ในชั้นสอบสวนและคำให้การของผู้เสียหายที่ 1 ในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์เอกสารหมายเลข 2 ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 ให้การว่า ขณะที่จำเลยนำอวัยวะเพศของจำเลยไปถูกอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 จำเลยและผู้เสียหายที่ 1 ยืนอยู่ แต่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ขณะที่จำเลยนำอวัยวะเพศของจำเลยมาถูกอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 นั้น จำเลยยืนย่อตัวเล็กน้อย ส่วนผู้เสียหายที่ 1 ก็ยืนอยู่ด้วย ซึ่งยังมีความแตกต่างและขัดกันอยู่ในลักษณะของการกระทำความผิดของจำเลยนั้น เห็นว่า จากภาพและเสียงจากแผ่นวิธีดีที่ผู้เสียหายที่ 1 ให้การไว้ในชั้นสอบสวนและคำให้การของผู้เสียหายที่ 1 ในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์เอกสารหมายเลข 2 และจากคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านแล้วได้ความว่าขณะที่จำเลยพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 นั้น ทั้งจำเลยและผู้เสียหายต่างอยู่ในท่ายืน เพียงแต่ในชั้นพิจารณาผู้เสียหายที่ 1 เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านเพิ่มเติมว่า จำเลยยืนย่อตัวเล็กน้อยซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดที่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มิใช่ข้อพิรุธที่จะทำให้คำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 มีน้ำหนักน้อยลงถึงกับรับฟังไม่ได้ ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน รวมทั้งนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพให้พนักงานสอบสวนถ่ายรูปไว้ ซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำเลยยังไม่ทันมีเวลาคิดหาข้อแก้ตัวให้พ้นผิด ที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้อ่านข้อความก่อนลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการจับกุมเนื่องจากจำเลยตกใจ และจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพราะเข้าใจว่าหากรับสารภาพฐานกระทำอนาจารก็เพียงแค่เสียค่าปรับ ส่วนภาพถ่ายประกอบคำรับสารภาพนั้นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้โดยขณะนั้นยังไม่มีภาพถ่ายให้ดูแต่อย่างใดนั้น เป็นเพียงคำกล่าวอ้างขึ้นมอลอยๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง เชื่อว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนรวมทั้งนำชี้ที่

เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพด้วยความสมัครใจ คำรับสารภาพและการนำชี้ที่เกิดเหตุของจำเลยจึงมีน้ำหนักรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำความผิดของจำเลยนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ กล่าวคือ ผู้เสียหายที่ 1 เป็นเด็ก อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 มีขนาดเล็ก จำเลยไม่สามารถที่จะนำอวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่ อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ได้อย่างแน่แท้ นั้น ข้อนี้เห็นว่า การกระทำที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือวัตถุซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถจะกระทำให้บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เช่น หญิงไม่มีช่องคลอด อันเป็นการผิดปกติมาแต่กำเนิด ซึ่งอย่างไรๆ อวัยวะเพศชายก็ไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงดังกล่าวได้ แต่คดีนี้ได้ความจากนาย ฐ. พยานโจทก์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายที่ 1 ว่า หากจะมีการร่วมประเวณี อวัยวะเพศชายจะเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายที่ 1 ได้ยากมาก โดยอวัยวะเพศชายสามารถเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายที่ 1 ได้ แต่ช่องคลอดก็จะฉีกขาด และการที่อวัยวะเพศชายจะเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายที่ 1 นั้น จะต้องมีการบังคับขู่เข็ญหรือใช้สารหลอกล่อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรณิดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่กรณีที่ปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำผิดไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามความหมายในมาตรา 81 สำหรับฎีกาข้ออื่นของจำเลยเป็นปัญหาปลีกย่อย แม้วินิจฉัยไปก็ไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง รับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่า จำเลยพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 จริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ศุภชัย สมเจริญ-ศิริชัย จิระบุญศรี-สมศักดิ์ อเนกพุฒิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ